



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



MÉRITO

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 06/11/2024 – SECÇÃO MUNICIPAL

EXAMES PRÉVIOS DE EDITAL

Processos: TC-018904.989.24-1 e TC-018908.989.24-7.

Representantes: - DB Serviços Médicos Ltda., por seus Advogados Rafael Cavalcanti de Oliveira, OAB/SP nº 320.197 e Raul Saraiva Pereira, OAB/SP nº 427.069.

- Márcio Almeida Santos.

Representada: Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra.

Responsável: Maria da Penha Agazzi Fumagalli (Prefeita).

Advogados: Sandra Regina Borges de Oliveira, OAB/SP nº 133.662; Vivian Valverde Corominas, OAB/SP nº 241.835; Clayton Machado Valério da Silva, OAB/SP nº 212.125; Leandro da Rocha Bueno, OAB/SP nº 214.932; e Marcela de Carvalho Carneiro, OAB/SP nº 230.471.

Assunto: Representações contra o edital do Pregão Presencial nº 25/2024 (Proc. nº 1565/2024), da Prefeitura de Rio Grande da Serra, que objetiva a contratação de empresa para prestação de serviços de assistência à saúde, compostos por atividades médicas, serviços de diagnósticos: Raio X, Ultrassonografia e Laboratorial, com fornecimento de equipamentos e de mão de obra, destinados a complementar e atender as necessidades das Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 12 (doze) meses.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, Senhora Procuradora do Ministério Público de Contas,

Em exame Representações formuladas por **DB Serviços Médicos Ltda. e Márcio Almeida Santos** contra o edital do Pregão Presencial nº 25/2024 (Proc. nº 1565/2024), da Prefeitura de Rio Grande da Serra, que objetiva a contratação de empresa para prestação de serviços de assistência à saúde, compostos por atividades médicas, serviços de diagnósticos: Raio X, Ultrassonografia e Laboratorial, com fornecimento de equipamentos e de mão de obra, destinados a complementar e atender as necessidades das Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 12 (doze) meses.

Em linhas gerais, os representantes criticam os seguintes aspectos do ato convocatório:

I - DB Serviços Médicos Ltda.:

- a) Previsão de cota reservada e exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte (lotes 03 e 05), que não encontra respaldo nas disposições da Lei nº 14.133/2021;
- b) O edital não prevê a apresentação, pelos proponentes, de registro em conselho de classe para as atividades de enfermagem (COREN), sendo certo que, embora o Termo de Referência mencione a participação desses profissionais na execução dos serviços, a descrição é omissa quanto a isso, ferindo a competitividade; e
- c) Ainda que o edital solicite certidão de regularidade junto à Fazenda Estadual, não exige certidão da dívida ativa na referida esfera de governo, além de não se justificar a comprovação acerca do ICMS, tributo que não guarda correlação com a atividade licitada.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



Conclui requerendo a adoção de medida liminar que determine a suspensão do certame, com posterior determinação de correção dos pontos impugnados.

II - Márcio Almeida Santos:

- a) Violação ao princípio da isonomia, ante a possibilidade de participação na disputa de Organizações Sociais e entidades afins, as quais gozam de isenções tributárias;
- b) A eventual contratação de OSS, ONG's ou entes análogos, que não possuem fins lucrativos, expõe a Administração a risco de responsabilidade de obrigações trabalhistas conforme súmula nº 331 do TST;
- c) A natureza jurídica das Organizações Sociais impede que elas disputem atividade econômica, vez que, nos termos da Lei Federal nº 9.637/98, sua finalidade é celebrar com o poder público contrato de gestão, de natureza de convênio, com formação de parceria, o que não se qualifica como contrato administrativo típico, ou seja, relação de mútua colaboração; e
- d) Inviabilidade da gestão de mão de obra pretendida com a contratação de tais entes, recomendando que para o objeto em questão seja contratada empresa privada.

Ao final, requer seja determinada a reforma do edital, para que nele seja incluída vedação à participação de Organizações Sociais, Organizações não Governamentais (ONG's), institutos ou entidades sem fins lucrativos.

Ante o vislumbre, em tese, de risco à higidez da licitação, em contrariedade às normas de regência da matéria e à orientação desta Corte, com fundamento no § 2º do artigo 171 da Lei n.º 14.133/2021, assinalou-se prazo para oferta de justificativas e encaminhamento de cópia integral do instrumento.

No interesse da lisura da licitação e, considerando que este Tribunal poderá decidir pela alteração do ato convocatório, determinou-se a suspensão do



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



procedimento questionado até apreciação final da matéria.

As medidas preliminares adotadas foram referendadas em Sessão Plenária de 18/09/2024.

Em resposta, a Administração compareceu aos autos, apresentando exemplar do edital e esclarecimentos.

Em relação à aventada incorreção na previsão de cota reservada e exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, sustentou que a Lei Complementar nº 123/2006 obriga tal reserva em licitações para sociedades nestas condições, promovendo tratamento diferenciado, tendo o ato convocatório sido confeccionado nos termos da legislação de regência, considerando que os lotes 03 e 05 atendem aos requisitos dos artigos 47 e 48 da mencionada norma e à orientação desta Corte.

No tocante à ausência de apresentação de registro em Conselho de Classe para as atividades de enfermagem (COREN), comprometeu-se a retificar o edital, a fim de prever a exigência.

No que se refere à comprovação de regularidade fiscal, argumenta que o instrumento exige que a pessoa jurídica contratada seja econômica e financeiramente idônea e esteja em dia com suas obrigações fiscais, a fim de garantir a execução eficaz do ajuste.

Nesse contexto, afirma que, independentemente da natureza do débito tributário (municipal, estadual ou federal), a inadimplência reflete falta de responsabilidade e pode comprometer a regularidade contratual.

Além disso, defende ser necessário demonstrar a correção da situação perante a Fazenda Estadual, incluindo tanto débitos inscritos quanto não inscritos na dívida ativa.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



No que tange à apontada ausência de vedação de participação de Organizações Sociais e afins, pondera que a Nova Lei de Licitação não proíbe explicitamente a participação de instituições sem fins lucrativos em licitações, mas também não a inclui, como a Lei Federal nº 8.666/93, que contava com disposição que levava à conclusão sobre a possibilidade de participação de tais entidades nesses processos.

Nesse contexto, entende que a vedação à participação de Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), prevista no edital, estende-se também às Organizações Sociais e demais entes sem fins lucrativos.

Além disso, pondera que o ato convocatório prevê, em vários dispositivos, que a licitação é destinada exclusivamente a empresas para a prestação dos serviços licitados, não fazendo nenhuma menção à participação de entidades do terceiro setor.

Por fim, pleiteia sejam as representações julgadas improcedentes.

A **ATJ**, acompanhada de sua **Chefia**, opina pela **procedência** parcial da representação intentada por DB Serviços Médicos Ltda. (TC-018904.989.24-1) e pela **procedência** da representação formulada por Márcio Almeida Santos (TC-018908.989.24-7).

No mesmo sentido foram as manifestações do **MPC** e da **SDG**.

É o relatório.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



MÉRITO

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 06/11/2024 – SECÇÃO MUNICIPAL

EXAMES PRÉVIOS DE EDITAL

Processos: TC-018904.989.24-1 e TC-018908.989.24-7.

Representantes: - DB Serviços Médicos Ltda., por seus Advogados Rafael Cavalcanti de Oliveira, OAB/SP nº 320.197 e Raul Saraiva Pereira, OAB/SP nº 427.069.

- Márcio Almeida Santos.

Representada: Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra.

Responsável: Maria da Penha Agazzi Fumagalli (Prefeita).

Advogados: Sandra Regina Borges de Oliveira, OAB/SP nº 133.662; Vivian Valverde Corominas, OAB/SP nº 241.835; Clayton Machado Valério da Silva, OAB/SP nº 212.125; Leandro da Rocha Bueno, OAB/SP nº 214.932; e Marcela de Carvalho Carneiro, OAB/SP nº 230.471.

Assunto: Representações contra o edital do Pregão Presencial nº 25/2024 (Proc. nº 1565/2024), da Prefeitura de Rio Grande da Serra, que objetiva a contratação de empresa para prestação de serviços de assistência à saúde, compostos por atividades médicas, serviços de diagnósticos: Raio X, Ultrassonografia e Laboratorial, com fornecimento de equipamentos e de mão de obra, destinados a complementar e atender as necessidades das Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 12 (doze) meses.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



EMENTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ATIVIDADES MÉDICAS E SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS. EXIGÊNCIA DE PROFISSIONAL REGISTRADO NO COREN. INDEVIDA REQUISIÇÃO DE PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA AO ICMS. IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL E PROCEDÊNCIA.

Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, Senhora Procuradora do Ministério Público de Contas,

O certame em análise prevê a contratação de empresa para a prestação de serviços de assistência à saúde, compostos por atividades médicas, serviços de diagnósticos: Raio X, Ultrassonografia e Laboratorial, com fornecimento de equipamentos e de mão de obra, de forma complementar.

De início, aborda-se a insurgência despida de fundamento.

Com efeito, diversamente do sustentado na exordial, e nos termos do posicionamento unânime dos órgãos de instrução, não vislumbro irregularidade na previsão de cotas reservadas para microempresas e empresas de pequeno porte constantes dos lotes 03 e 05, uma vez que, além de o objeto ser divisível, os valores estimados encontram-se em conformidade com os limites previamente definidos na Lei Federal nº 14.133/21¹, aplicando-se, por consequência, os artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/06, que

¹ “Art. 4º Aplicam-se às licitações e contratos disciplinados por esta Lei as disposições constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

§ 1º As disposições a que se refere o caput deste artigo não são aplicadas:

I - no caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços em geral, ao item cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;”



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



Na sequência, a Administração se comprometeu a requisitar, no tocante ao lote 01, registro do profissional no Conselho Regional de Enfermagem, medida essa que soa adequada, ao menos neste momento, para assegurar a prestação dos serviços correspondentes em conformidade com a legislação regente do setor específico do objeto da disputa.

Dando seguimento, em relação à comprovação da regularidade fiscal, especificamente no que diz respeito aos débitos atinentes ao ICMS, constante do item 5.3, inciso III, alínea “b”, o ato convocatório merece retificação, uma vez que o imposto em questão ultrapassa o objeto em disputa, nos termos da orientação desta Casa, conforme exposto no voto condutor dos TC’s-017471.989.24-4 e 017622.989.24-2:

“De início, conforme destacado na medida liminar, e confirmado pela instrução, deve ser revista a cláusula que trata de regularidade fiscal. Inobstante o edital mencione que a certidão deve ser “pertinente ao ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com a prestação licitada”, faz expressa menção ao ICMS, tributo que desborda do escopo da contratação, o que impõe seja ele excluído do subitem 7.1.h.2.”

Ainda sobre o tema, não há impedimento para que a Municipalidade possa exigir demonstração da situação perante a Fazenda Estadual em relação a outros tributos e taxas, desde que evidenciada a pertinência ao ramo de atividade das licitantes e a compatibilidade com o objeto contratual.

No tocante à crítica remanescente, atinente à ausência de vedação de participação de entidades sem fins lucrativos, vinculadas ao terceiro setor, acolho as manifestações unânimes de ATJ e MPC no sentido de que esta Casa já firmou posicionamento em relação à impossibilidade de atuação de tais entes em certames



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



com pretensão similar àquela ora em disputa, considerando eventuais prejuízos à isonomia e à competitividade, a exemplo do julgado no TC-016582.989.24-0².

Dessa forma, não vislumbro cenário favorável ao acolhimento das argumentações da Prefeitura de que o edital utiliza a expressão "empresa" em diversos trechos e que a "vedação à participação de Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP" na licitação, constante do item 3.2.1, alínea "g" se estenderia às Organizações Sociais e outras instituições sem fins lucrativos, sendo a impugnação procedente.

Ante o exposto, nos estritos limites dos aspectos abordados, voto pela **procedência parcial** da representação intentada por DB Serviços Médicos Ltda. e pela **procedência** daquela apresentada por Márcio Almeida Santos, para determinar que a **Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra** altere o edital do **Pregão Presencial nº 25/2024**, a fim de:

- a) afastar a exigência de comprovação de regularidade fiscal relativa ao ICMS;
- b) explicitar, de forma inequívoca, a impossibilidade de participação de qualquer entidade sem fins lucrativos; e
- c) incluir, na forma como se comprometeu, a requisição de registro do profissional no Conselho Regional de Enfermagem (COREN) em relação ao lote 01.

Após proceder às alterações, os responsáveis pelo certame deverão proceder à nova publicação do instrumento e reabertura de prazo para formulação de propostas.

² Sessão Plenária de 09/10/2024, sob relatoria do eminente Conselheiro Dimas Ramalho.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



Expeçam-se os ofícios necessários, encaminhando os autos, após o trânsito em julgado, para arquivamento.

É como voto.